

1500809-34.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO MOTIVADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO HABITUAL À TRAFICÂNCIA: QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500809-34.2021.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500809-34.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2277832/2021 - 04º D.P. AMERICANA, 20769917 - 04º D.P. AMERICANA, 1478/21/350 - 04º D.P. AMERICANA, 2277832 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 1478/21/350 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (16 porções da droga conhecida como COCAÍNA, pesando 1 grama; e 18 porções da droga conhecida como CRACK - derivada da cocaína, pesando 4,3 gramas) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia de fls. 90/91, foi recebida em 10 de janeiro de 2022 (fls. 136/142).

O réu foi citado (fls. 114), apresentando defesa (fls. 123/128).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 155/156).

Em seus memoriais (fls. 160/168), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

A Doutora Defensora do réu (fls. 171/182), requereu a absolvição por falta de provas, a desclassificação para o delito de uso pessoal, ou a aplicação do tráfico privilegiado.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelos laudos de fls. 63/65.

É notório o perigo à incolumidade pública causado pela droga conhecida como cocaína (inclusive na forma derivada - CRACK), de alto poder viciante e que causa dependência física e psíquica, demonstrando estar plenamente caracterizada a prática delitativa.

De acordo com a doutrina:

"É tão grave a nocividade dessa droga que, mesmo depois da cura pela desintoxicação, o viciado não se recupera das lesões mais graves do sistema nervoso. Tem estados depressivos e de angústia, alucinações visuais e tácteis, delírios de perseguição e complexo de culpa. Envelhece muito precocemente, e a morte é quase sempre por perturbações cardíacas" (DE FRANÇA, GENIVAL VELOSO. Medicina Legal. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, p.308).

A esse respeito, a matéria publicada no conceituado jornal "Folha de São Paulo"; em 30 de dezembro de 1994:

"Cocaína é maior causa de infarto em jovens

A cocaína é responsável por quase todos os infartos do miocárdio em jovens com menos de 30 anos. A constatação é da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) que lança na próxima semana uma campanha nacional de informação.

O objetivo é esclarecer as pessoas sobre as doenças do coração e o que se deve fazer para evitá-las. Entre os jovens, o uso da cocaína é o que mais preocupa a SBC.

"Eles precisam saber que a cocaína tem efeitos mortais no organismo", diz Claudio Buarque Benchimol, 47, secretário-geral da SBC. "Quase todos os jovens que chegam com infarto nos hospitais fizeram uso de cocaína", afirma.

É o que acontece no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas, umas das mais importantes portas de entrada de vítimas de infarto em São Paulo.

O cardiologista Marcello Barduco, do pronto-socorro do Incor, confirma que entre os jovens a causa do infarto está quase sempre associada ao uso de cocaína.

O hospital registra uma média de um a três casos de infartos em jovens por mês. A cada 24 horas, o Incor recebe uma média de cinco vítimas de infarto, idosos na grande maioria.

Não há estudos sobre os riscos nem estatísticas sobre casos de infarto por droga entre jovens. De acordo com Benchimol, o número de mortes do coração provocado por cocaína pode estar subnotificado por interferência da família. Ou mesmo pela

dificuldade em se apontar a droga como causa.

De todo modo, o número de jovens que morrem por infarto é pequeno. Segundo dados da Fundação Seade, apenas 33 jovens entre 15 e 29 anos morreram de infarto do miocárdio na cidade de São Paulo no ano passado. Para se ter uma idéia, nesse mesmo período, 2.298 jovens dessa faixa de idade foram assassinados com armas de fogo e outras armas. Outros 561 morreram no trânsito.

A preocupação da SBC é com o aumento do uso da cocaína registrado nos últimos anos. "O número de usuários dessa droga vem aumentando no mundo todo", diz Benchimol.

Pesquisa feita entre estudantes de 1º e 2º graus de dez capitais brasileiras mostra que 1,2% deles já experimentou cocaína. Cinco anos atrás, apenas 0,7% dos estudantes tinham usado a droga uma vez. A pesquisa foi feita pelo Cebrid, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas.

O perigo da cocaína é apenas um dos itens da campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os médicos pretendem informar em linguagem simples como se iniciam as doenças do coração e o que pode agravá-las ou fazer com que regredam.

A hipertensão arterial e o fumo, por exemplo, são fatores de risco para um infarto. Alimentação correta, pouco estresse e exercícios físicos ajudam a manter o coração mais saudável."

E ainda:

"A quantidade necessária para provocar uma overdose varia de uma pessoa para outra, e a dose fatal vai de 0,2 a 1,5 grama de cocaína pura. A possibilidade de overdose, entretanto, é maior quando a droga é injetada diretamente na corrente sanguínea. O efeito da cocaína pode levar a um aumento de excitabilidade, ansiedade, elevação da pressão sanguínea, náusea e até mesmo alucinações.

(...)

A cocaína é a droga que mais rapidamente devasta o usuário. Bastam alguns meses ou mesmo semanas para que ela cause um emagrecimento profundo, insônia, sangramento do nariz e coriza persistente, lesão da mucosa nasal e tecidos nasais, podendo inclusive causar perfuração do septo (12). Doses elevadas consumidas regularmente também causam palidez, suor frio, desmaios, convulsões e parada respiratória". (S.H. Cardoso e R.M.E. Sabbatini; Revista Cérebro & Mente 3(8), jan/mar 1999).

A autoria, relativo ao tráfico, é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os policiais militares informaram que se encontravam em patrulhamento, e na rua dos fatos avistaram dois indivíduos, sendo que um indivíduo, ou seja, o réu entregava algo ao outro. Disseram, ainda, que ao visualizarem a viatura, o réu dispensou algo ao solo, e ambos evadiram-se, sendo que o policial Pedro saiu em perseguição e conseguiu abordar o réu. Em revista pessoal localizaram com o réu, em seu bolso, 17 porções de crack e 16 microtubos de cocaína, além de uma quantia dinheiro, cerca de R\$ 95,00. No objeto dispensado, localizaram mais uma porção de crack, semelhante as encontradas com o réu. Indagado, o réu declarou que a droga era destinada ao tráfico em um bar próximo. Por fim, o informaram que o local é conhecido como ponto de tráfico.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas” (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - (...). (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares – Inocorrência – Decisão motivada – Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados – Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida – Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados – (...) – Sentença mantida – Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

APELAÇÃO – tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. Art. 59, CP – pena fundamentada, critério trifásico obedecido, regime prisional com

previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Não procedem as alegações da defesa quanto à divergência/imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

Tráfico de entorpecentes - Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 21,5 gramas de cocaína, em pó - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes. (TJSP; Apelação Criminal 0003382-85.2013.8.26.0538; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

PROVA - Depoimento de Policiais - Valor:70(a) - Os testemunhos de Policiais possuem validade jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis, inexistindo qualquer vedação legal, sendo certo que, a simples condição de Policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (Apelação nº 1.179.625/0, Julgado em 22/02/2.000, 14ª Câmara, Relator: Oldemar Azevedo, RJTACRIM 47/274)

A quantidade e forma de acondicionamento do tóxico apreendido, além da quantia em

dinheiro, somada a tentativa de fuga por parte do réu, evidencia a destinação de tráfico.

Ainda que se considere pequena a quantidade que o réu portava, já ficou patente que os "patrões" do tráfico costumam utilizar-se de pequenos traficantes para a venda. Confira-se à respeito, a matéria do Jornal "O Liberal" de Americana, no dia 21 de junho de 2009:

MICROTRAFICANTES VIRAM O PRINCIPAL FOCO

DA POLÍCIA - Os microtraficantes, como são chamadas pela polícia as pessoas que vendem pequenas quantidades de drogas, são o novo foco dos investigadores da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). "Esse tipo de traficante é como erva daninha. Quanto mais se prende, mais surge. Por isso temos de combatê-los. Queremos chegar no 'patrão' que está no topo e na base da pirâmide do tráfico", disse o delegado Marco Antonio Pozzetti, titular da DISE. Na semana passada, cinco microtraficantes foram presos. Esta forma de comércio foi criada pelos 'patrões' do tráfico para não sofrerem grandes baixas quando a polícia age. Cada micro fica no ponto de venda, conhecido como 'biqueira', com no máximo 20 unidades de entorpecentes (pedrinhas de crack, papelotes de cocaína e pequenos embrulhos de maconha). Eles são abastecidos pelos 'gatos' como os 'patrões' identificam os distribuidores.

"Os investigadores estão saindo às ruas à procura dos microtraficantes. Na quinta-feira, por exemplo, prendemos um que vendia drogas sentado em um sofá na calçada de sua casa, no Jardim Guanabara. Com ele nós encontramos seis pedrinhas de crack, dois pedacinhos de maconha e mais R\$ 30,00. É o exemplo do microtraficante. Ele estava com uma quantidade reduzida". Disse o delegado da DISE. "O surgimento dos microtraficantes é uma forma criada pelos 'patrões' do tráfico para evitar grandes tombos. Prendemos muitas pessoas e a quantidade de entorpecente apreendida é pequena. Assim, a 'biqueira' não sofre prejuízo", contou o delegado.

Uso próprio

As pessoas que são presas também tentam se beneficiar do artifício da pequena quantidade. Eles procuram provar, na Justiça, que o entorpecente é para uso. Assim, tentam 'quebrar' a prisão de tráfico para uso de entorpecente. "A maioria alega que estava com aqueles papelotes ou pedrinhas para consumo próprio", afirmou um dos investigadores da DISE. Pozzetti instruiu os policiais a agirem nas duas pontas da pirâmide do tráfico. "Os micros estão na base e fazendo prisões. Nós conseguimos enfraquecer e até chegar aos donos do comércio", comentou. Os policiais aproveitam as prisões para fazer um mapeamento do esquema do tráfico em Americana. "Nós já sabemos, por exemplo, quem são os responsáveis pelas principais biqueiras. São informações que surgem com as prisões desses microtraficantes", disse o policial. O perfil do vendedor de pequenas quantidades de droga é diversificado, conforme avaliam os policiais da DISE. São adolescentes, jovens e até crianças. Um número cada vez maior de mulheres tem atuado nas 'biqueirinhas' como costuma chamar o delegado. (...) Em Americana, as prisões aconteceram no Jardim Guanabara, Vila Bela, Parque da Liberdade, São Roque, São Jerônimo e na Praia Azul. (...) "O Jardim Guanabara, em Americana, por exemplo, aparece como uma das áreas de grande concentração de pequenos pontos de venda de drogas e vamos intensificar nosso trabalho" afirmou Pozzetti.

Cumprido destacar que o local onde o réu foi preso é conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas.

O acusado Leonardo negou a prática do delito. Disse que a droga encontrada (16 porções) era para consumo pessoal e de sua genitora. Declarou, ainda, que foi o traficante quem saiu correndo.

No entanto, a versão pueril do réu em juízo, restou isolada no conjunto probatório.

O fato do réu já ter sido apreendido por delito envolvendo substância entorpecente (B.O. de fls. 74/76), além de outros registros de atos infracionais pelo delito de tráfico (certidão de fls. 33 - Proc. 0004768-14.2020.8.26.0019 e Proc. 0010225-32.2017.8.26.0019), é outro indício do envolvimento do réu com as substâncias ilícitas, fato que fortalece a convicção judicial, embora por si só não possa ser considerado como prova. Já decidiram nossos tribunais: PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o *fumus commissi delicti*, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o *periculum libertatis*, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTACRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

Desta forma, a quantidade e variedade de droga, a forma de acondicionamento, os objetos e/ou o valor em dinheiro de origem não elucidada, permitem a segura conclusão de que o entorpecente apreendido era destinado ao tráfico, razão pela qual é impossível, ainda, a desclassificação para o consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06). Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Incabível. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Redução da pena conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Inadequada. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos representam perigo maior, atingindo incontáveis usuários, além de apresentarem alto risco à saúde pública com a colocação de tamanha quantidade de entorpecentes na rua - Ademais, as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação habitual do apelante à prática

do crime de tráfico ilícito de drogas, não se tratando de mero traficante eventual, que, por descuido, envolveu-se com a traficância momentaneamente - (...) - Pena e regime mantidos Recurso desprovido. (Apelação Criminal nº 0002456-25.2017.8.26.0616, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Presença de indícios tipificadores do delito - Apreensão de grande quantidade de entorpecente - Excessivo poder de compra que não se adequa à condição simples do réu - Aplicação dos artigos 12 e 37 da lei 6368/76 - Recurso não provido. (Relator: Gentil Leite - Apelação Criminal n. 161.748-3 - Campinas - 01.09.94)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Ré surpreendida na posse expressiva quantidade de maconha e uma porção de cocaína - Quantidade e natureza da droga que evidencia o objetivo de mercancia - Recurso não provido. (Relator: Segurado Braz - Apelação Criminal n. 161.094-3 - São José do Rio Preto - 16.05.94)

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, tendo em vista que a extrema nocividade da cocaína, exigindo especial rigor no combate ao seu tráfico, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, pela necessidade de impor ao traficante pena de severidade correspondente ao elevado risco que o comércio dessa nefanda substância acarreta à saúde pública.

O réu agiu reprovadamente com vontade livre e consciente, dirigida à prática de condutas que representam tráfico de cocaína, droga especialmente perigosa, colocando em grave perigo a saúde pública, acrescendo como circunstância a quantidade expressiva da droga, tendo como motivo o propósito de locupletamento, vale dizer, ganho fácil e espúrio.

Com efeito, segundo Damásio:

"O novo sistema penal prevê duas fases na aplicação da pena. Num primeiro momento, com fundamento no princípio da pena retributiva, fixa sua qualidade e quantidade, elaborando um juízo sobre o passado (juízo de culpabilidade), atendendo à gravidade objetiva do delito, antecedentes e personalidade do agente, sua conduta social anterior, motivos determinantes do fato e suas conseqüências." (Damásio Evangelista de Jesus, "Direito Penal", Parte Geral, 1 volume, 19ª Edição, Saraiva, 1995, p. 509)

Havendo uma graduação de penas, é evidente que a pena mínima, deve ser aplicada, por exemplo, àqueles que comercializam pequena quantidade de "maconha", tóxico muito menos grave e nocivo que a cocaína, que envolve interesses de grupos altamente perigosos, que para a sua difusão e fabricação se organizam freqüentemente em quadrilhas, patrocinando "chacinas", segundo diariamente noticiado nos jornais. Destarte é indiscutível que a cocaína apresenta um perigo muito maior, uma maior potencialidade de dano social. Como dito acima, a cocaína freqüentemente leva à morte, além de ser porta para outros tipos de tóxicos mais graves, como a heroína, por exemplo.

A propósito, julgando feito em trâmite por este juízo, assim decidiu a Egrégia 11ª Câmara Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo relator foi o Desembargador Di Rissio Barbosa, do seguinte teor:

Comércio Clandestino de entorpecente. Pena. Exacerbação decorrente da natureza da droga, "crack", cujos efeitos são mais graves que outras drogas. Não é só admissível a exacerbação, como também recomendável por diferenciar situações

dispares. (Apelação 455.718.3/1-00, 8 de junho de 2005).

Da brilhante decisão, destaco o seguinte trecho:

"...o aumento decorrente do tipo de droga, de extrema consequência, foi adoção que todos os Magistrados deveriam ter em mente ao calcular a pena; realmente, não se pode deferir a mesma repressão aos que se envolvem com drogas consideradas leves, pelas consequências que determinam, e outras consideradas pesadas, aqui com maior desprezo ao infeliz semelhante usuário".

Além disso, existe o imperativo legal do artigo 42 da Lei 11.343/2006, segundo o qual a quantidade e natureza da droga devem preponderar sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal no momento de fixação da pena base.

Segundo o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 1,956 KG DE COCAÍNA. LEGALIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO ÓRGÃO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 17/10/2019) e que "[i]nexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio [...]" (HC 448.085/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) 2. No caso, a majoração da pena-base em 2 (dois) anos está suficientemente fundamentada, pois as vetoriais previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 foram sopesadas negativamente em razão da apreensão de 1,956 kg (um quilograma e novecentos e cinquenta e seis gramas) de "cocaína". 3. O quantum de majoração adotado não se mostra desarrazoado ou desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito (de 5 a 15 anos de reclusão), bem como a natureza e elevada quantidade da droga apreendida. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 536.692/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. MODIFICAÇÃO DE REGIME. PLEITO PREJUDICADO, ANTE A MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. ADEMAIS, PENA SUPERIOR A 7 ANOS E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É cediço que, quanto à exasperação da pena-base no crime de tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, verifico que a pena-base foi exasperada em razão da variedade/quantidade das drogas (48,759kg de cocaína e 1,011kg de crack), fundamentos idôneos para majorar a pena-base e recrudesce o regime prisional. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC 505.140/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido. (AgRg no RESp 1793804/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,

julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

Assim sendo, exaspero a pena base em 1/6 (um sexto), considerado o mínimo, delimitando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na segunda fase, diante da circunstancia atenuante (art. 65, inc. I, do CP), reduzo a pena, retornando-a ao patamar mínimo, ou seja, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em que pese ser o réu tecnicamente primário, considerando a quantidade de drogas apreendidas, somada a existência de antecedentes em atos infracionais pelo delito de tráfico (fls. 33), além de processo de porte de arma de fogo (Proc. 1510813 - certidão de fls. 32), pouco tempo antes da ocorrência dessa demanda, o que acarreta a existência de dedicação a atividades criminosas, resta impossível a aplicação do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11343/2006.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REINCENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO

DESPROVIDO. I - (...). III - Quanto ao tráfico privilegiado, o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - In casu, a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente é reincidente, não preenchendo, portanto, o requisito legal da primariedade para o privilégio. V - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou orientação no sentido de que até mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedicaria às atividades criminosas. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 600.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO MOTIVADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO HABITUAL À TRAFICÂNCIA: QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 E QUE NÃO EXCEDE 8 ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram a prática delitativa, com destaque para a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos. 2. Hipótese em que a quantidade da droga apreendida, apesar de embasar a exasperação da pena-base, não foi utilizada para definir o patamar da fração redutora, mas, sim, como um dos elementos de convicção para concluir que o paciente traficava com habitualidade e, conseqüentemente, não preenche um dos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, não se dedicar a atividades criminosas. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,

decidido, por ambas as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. (AgRg no HC n. 528.444/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 19/11/2019). 4. (...). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 613.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável ao acusado, a saber, a natureza e quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, o que impossibilita a adoção de regime mais brando, segundo a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso da Defesa – Tráfico de drogas – Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da lei de drogas – Inadmissibilidade – Ademais, ficou bem evidenciado que o acusado trazia consigo as drogas para fornecimento a terceiros, em atividade típica de tráfico – Tráfico bem caracterizado pelas provas dos autos – Regime prisional mais brando – Inadmissibilidade – Acertado o regime prisional fechado para o réu, não se podendo olvidar que se trata de acusado reincidente, merecendo tratamento penal mais severo – (...) – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500257-28.2018.8.26.0613; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO MOTIVADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO HABITUAL À TRAFICÂNCIA: QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 E QUE NÃO EXCEDE 8 ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS SOPESSADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 5. A valoração negativa da quantidade de entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso. Precedentes. 6. No caso, embora o paciente seja primário, condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 e que não excede 8 anos de reclusão, as circunstâncias do crime - expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos -, sopesadas na primeira fase da dosimetria, mostram-se idôneas e suficientes para o recrudesimento do regime prisional, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 613.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Nos termos do entendimento da jurisprudência (TJSP, 993.07.126969-7, 6ª Câmara, Rel. Des. MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA, j. 25.02.201), de acordo com a Lei n. 11.464, de 28 de março de 2007, cabendo ao Juízo das Execuções Criminais a análise do eventual preenchimento dos requisitos para a concessão de progressão. Se assim não fosse, não teria sentido algum outro regime a ser fixado. O legislador, ao tratar o traficante de drogas equiparado a hediondo, negou-lhe vários benefícios que a outras espécies de criminosos seriam cabíveis, como fiança, indulto, sursis, liberdade provisória etc. Assim, não faria sentido que, condenados, esses infratores recebessem pena alternativa ou cumprissem as reprimendas em regime diverso ao fechado.

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS – CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO, AINDA QUE EM SUA

MODALIDADE "PRIVILEGIADA". REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. 1) A determinação de cumprimento da pena em regime inicial fechado, para condenados por tráfico de drogas, decorre de exigência expressa na Lei de Crimes Hediondos e na Lei nº 11.343/06. Decisões permissivas dotadas de efeitos "inter partes", não se registrando declaração de inconstitucionalidade "erga omnes" dos indicados dispositivos - Precedente do C. STJ - Maior rigor na repressão de crimes desse jaez, nos termos da CF/88. Compatibilidade, de qualquer forma, com a gravidade concreta dos fatos. 2) Substituição da corporal por restritivas de direitos - Impossibilidade - Circunstâncias concretas a indicar a insuficiência da imposição de pena restritiva de direitos - Art. 44, III, do CP. (TJSP; Apelação Criminal 0009095-78.2015.8.26.0309; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2016; Data de Registro: 17/05/2016)

Assim também se posicionou a 7ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"No tocante ao regime prisional, deve prevalecer o fechado, por força de expressa previsão legal e o montante das penas carcerárias inviabiliza eventual substituição por restritivas de direitos. Afinal, os mercadores de entorpecentes criam um poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade ordeira". (Relator Des. Roberto Mortari, j. 22.05.2014).

O réu não pode apelar em liberdade por vedação expressa contida no artigo 44 da Lei 11.343/2006.

Além disso, o delito de tráfico de entorpecentes é considerado como crime hediondo nos termos da Lei 8.072/90. A gravidade do delito não autoriza a concessão do benefício. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

Habeas Corpus - Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) - Sentença condenatória proferida em 01/10/2019 - Impetração pleiteando a concessão do direito de apelar em liberdade - Impossibilidade - Custódia cautelar suficientemente fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo) - Embora não seja expressiva a quantidade de droga apreendida, o paciente registra maus antecedentes e é reincidente específico - Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a futura aplicação da lei penal - Ademais, não há sentido em que o réu, que permaneceu preso durante toda a fase instrutória, seja solto quando da prolação da sentença condenatória, na qual se materializam, ainda mais, a ilicitude, a culpabilidade e a punibilidade - Constrangimento ilegal não configurado - ORDEM DENEGADA. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2283715-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)

"Associação para a prática de tráfico de entorpecente (art. 14 da lei n 6.368/76) - condenação judicial - Recusa do benefício de apelar em liberdade - Inexistência de constrangimento ilegal - Irrelevância de inaplicável à espécie a regra do art. 35 da Lei 6.368/76, que proíbe o apelo em liberdade tão-só nos casos de condenação pelos delitos dos arts. 12 e 13. O benefício de apelar em liberdade pode ser validamente recusado a quem sofrer condenação penal pela prática do delito de associação criminosa, tipificado no art. 14 da Lei 6.368/76. A extrema gravidade objetiva desse fato e as circunstâncias pertinentes ao crime e à personalidade do agente constituem elementos a que os juízes e tribunais não podem ficar indiferentes. A periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa por ele desenvolvida, em face da grave repercussão social de que se reveste qualquer comportamento ilícito associado ao tráfico de entorpecentes. O fato de ser inaplicável ao paciente a regra inscrita no art. 35 da Lei Antitóxicos

não inibe o magistrado de recusar-lhe o benefício da apelação em liberdade, desde que o faça em ato decisório plenamente motivado". - HC n 67.750-9 - SP - 1ª T. do S.T.F. - j. 28.11.89 - Rel. Min. CELSO DE MELLO (RT. 652/382).

No mesmo sentido: RT 653/296, 655/350, 646/342 e 297, 627/281 e 347, 630/300, 633/386, 634/319, 636/295, 591/387, RJTJESP 120/586, 116/535.

O fomento que esse tipo de delito traz à prática de outros tipos de delito exige a manutenção do réu no cárcere, para a garantia da ordem pública. Pelo mesmo motivo, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois falta o requisito da suficiência.

Além disso, o réu Leonardo encontra-se preso por força de prisão em flagrante, e segundo a melhor doutrina, e jurisprudência majoritária, o dispositivo é inaplicável no caso de réu preso provisoriamente.

Segundo o ilustre penalista Damásio Evangelista de Jesus:

"Segundo o entendimento pacífico do STF, essa disposição é inaplicável a réu preso em razão de flagrante ou preventiva, uma vez que e/a visa apenas abrandar o princípio da necessidade de e/e recolher-se à prisão para apelar (RHC 54.430, DJU 26.11.76, p. 10203). Assim, réu que por ocasião de sentença condenatória se encontrava preso em razão de flagrante ou preventiva, embora primário e de bons antecedentes, não pode apelar em liberdade (RHC 55.109, DJU 27.5.77, p. 3459, RHC 56.953, DJU 27.4.79, p. 3381; RHC 58.286, DJU 3.10.80, p. 7735). Sobre o assunto, decidiu o TJSP que "Lei n. 5.941, de 1973, é de interpretação restrita. Não nulificou a prisão em flagrante delito, cuja permanência no sistema processual vigente, vai até a sentença. Se esta for absolutória, o réu será posto em liberdade. Se for condenatória, aquela permanência se prolonga, porque um dos seus efeitos (art. 393, I) é ser o condenado conservado na prisão. Se for de pronúncia, só então o magistrado deverá reexaminar a custódia provisória, para revogá-la caso satisfaça o agente os requisitos legais" (RT- 500/318). No mesmo sentido: RT 531/295 e RTJ 88/69; RHC 57.947, DJU 13.6.80, p. 4461, e RHC 58.053, DJU 12.8.80, p. 5786. E, se a acusação apela visando à agravação da reprimenda, o réu permanece detido, ainda que já tenha cumprido o quantum da pena imposta na sentença condenatória (Código de Processo Penal Anotado - Direito Informatizado Saraiva - 1ª Edição em CD-ROM - 1995).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Habeas Corpus - Tráfico de drogas e associação para este - Pleito visando o direito de apelar em liberdade - Inadmissibilidade - Existência nos autos de prova da materialidade do delito e, em tese, indícios de autoria - Decisão fundamentada de forma suficiente - Acusada que foi presa em flagrante, permaneceu custodiada ao longo de toda a instrução e, ao final, foi condenada - Fatores impeditivos da almejada liberdade para apelar em liberdade - Presença dos requisitos da prisão preventiva - Inexistência de constrangimento ilegal - Denegação da ordem. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2172499-63.2017.8.26.0000; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017)

"É que o paciente respondeu o processo preso cautelarmente, durante toda a instrução, hipótese em que, sobrevindo sentença condenatória, não há de permitir-se que apele solto, ainda que possua os atributos elencados pelo ilustre impetrante. Neste sentido, aliás, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui

um dos efeitos da respectiva condenação. 2. Na espécie, o réu, preso em flagrante, permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não caracterizando constrangimento ilegal a preservação da sua custódia pela sentença condenatória, mormente porque permanecem hígidos os motivos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. As condições pessoais favoráveis não são requisitos bastantes para a concessão de liberdade provisória, e, ademais, no caso dos autos, o paciente não logrou demonstrar ocupação lícita e possuir residência no distrito da culpa. 4. Habeas corpus denegado." (HC nº 207.906/RJ, Quinta Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.02.2012).

E, no caso sub judice persistem os requisitos para a manutenção da custódia do paciente, pois os delitos apurados roubo duplamente qualificado e associação criminosa armada demonstram a periculosidade do agente e a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicabilidade da lei penal. Sendo assim, não pode ser concedido ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em